

1500387-82.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500387-82.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500387-82.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2033874/2022 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 22847757 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 316/22/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2033874 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2033874 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 316/22/923 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENDOW WASHINGTON SOUZA TOMAZ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

BRENDOW WASHINGTON SOUZA TOMAZ, vulgo "Raridade", qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/06. BRUNO RODRIGO DA SILVA, vulgo "Dibala", por sua vez, está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei de Drogas.

Notícia o incluso inquérito policial que, no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 10h30min, na Rua Cinco, próximo ao nº 315, Jardim Residencial Ernesto Kuhl, nesta cidade e comarca, os acusados, agindo em concurso e idênticos propósitos, traziam consigo e guardavam, para comercialização com terceiros, aproximadamente 9,1g (nove gramas e um decígrama) da droga cocaína, na forma de vinte e nove pedras de crack, cerca de 9,91g (nove gramas e noventa e um centígramas) da droga cocaína, na forma de pó, acondicionada em vinte e três microtubos plásticos, e aproximadamente 407,1g (quatrocentos e sete gramas e um decígrama) da droga Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha, divididas em oitenta

porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notícia, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local acima descritas, BRENDOW portava um revólver calibre.38, da marca Rossi, com a numeração raspada, municiada com cinco cartuchos intactos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação dos réus para que apresentassem defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 171/180).

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2022 (fls. 195/197).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, com interrogatório dos réus ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 297/302) e da Defesa (fls. 331/338).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar de prova ilícita em razão da ilegalidade da busca pessoal será analisada em conjunto com o mérito da ação penal.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (18/21) auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), laudo pericial com resultado positivo para cocaína e maconha (fls. 102/104, 145/147 e 267/269), laudo pericial da arma (fls. 292/294), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em Juízo, o réu Brendow disse que tem 25 anos. É casado. Trabalha como barbeiro. Por volta das dez horas, foi na casa do seu primo Bruno. Foram na padaria. Faltava sete metros e havia dois rapazes parados, de nome Gabriel e Diego. Costumam jogar bola. Disseram que não iriam participar do futebol, iriam na padaria. A viatura policial virou do nada. Bruno e ele estavam de costa. Gabriel jogou arma ao solo e Diego saiu correndo. Ficaram Bruno e ele. Foram revistados. Falou que iria com seu primo Bruno na padaria. Foram presos. Falaram que ele foi preso por causa da arma de fogo dispensada. Na delegacia tomou socos dos guardas. Bruno tinha dinheiro em seu poder. Ele tinha cento e dez reais para comprar pão. Iriam jogar bola depois. O dia tinha começado. Os policiais localizaram drogas na árvore e lá tinham crianças. Acredita que as drogas eram de Gabriel e Diego. Não manteve qualquer contato com motociclista. Não tinha qualquer desavença com os policiais. Não integra qualquer organização criminosa. Nunca ficou preso. Às fls. 288/290, há fotografias de onde tomou tiro em 2016 e acredita que é perseguido (mídia).

Em Juízo, o acusado Bruno disse que tem 24 anos. É barbeiro. É casado. No dia em questão, saiu de sua casa. Encontrou Brendow. Falou que iriam à padaria e depois iriam jogar bola. Chegando perto da padaria encontraram Gabriel e Diego. Gabriel os chamou. Falou que iria tomar café da manhã. A viatura apareceu do nada. Diego e Gabriel correram. Gabriel soltou um revólver. Foram abordados. O policial Orlando algemou Brendow. Também foi algemado. Foram levados para fazer corpo de delito. Na delegacia Brendow foi agredido. Ficou indignado do seu primo apanhar. No local não

foram revistados, apenas na delegacia. Falou aos guardas que tinha dinheiro em seu poder. Só sua pochete e celular foram levados pelos guardas. Não tinha drogas na pochete. Nunca integrou facção criminosa. Nunca ficou preso. Não tem antecedentes criminais. Numa pracinha os policiais vieram com uma sacola. Jogava bola com Gabriel e Diego aos domingos. Não sabe o nome completo deles, não trouxe eles de testemunhas (mídia).

A versão dos acusados não convence.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses dos réus.

O policial militar William de Azevedo Ouvidio contou que estavam em operação próximo ao bairro quando chegou denúncia via Copom de pessoas pertencentes ao PCC em reunião no bairro Ernesto Kuhl e ataque à forças públicas. As características foram repassadas, um deles estava armado. Em razão da gravidade da ocorrência, foram até o bairro e no local indicado na denúncia viram uma motocicleta. O acusado Brendow fazia menção de estar entregando algo a um motociclista. Em busca pessoal com Brendow localizaram em sua posse uma bucha de maconha e na sua cintura um revólver calibre 38. Indagado, ele confirmou a prática do tráfico e a arma era para sua defesa em razão da guerra de facção com outra denominada Comando Vermelho. Foi indicado o local de mais drogas, encontraram mais 15 pedras de crack numa área verde. Havia mais 80 porções de maconha. Com o réu Bruno encontraram uma bolsa contendo 23 porções de cocaína, 14 pedras de crack e dinheiro. Indagado, Bruno disse que estava traficando desde às oito da manhã. A respeito do ataque aos policiais eles negaram. Ambos foram algemados. Os acusados costumam se apresentar como integrantes de facção criminosa, do PCC. Brendow tinha contato com motociclista e Bruno estava ao lado, eles estavam atuando em conjunto. Só estavam os dois no local da abordagem. Havia mais pessoas trafegando pelo bairro. Não teve enfrentamento com a população. O bairro em questão é complicado e muitas pessoas ali são coniventes com a traficância por receio da facção criminosa. Não foram hostilizados. Fizeram busca rápida. A arma estava municiada. A informação via Copom que chegou era de reunião e ataque às forças públicas. Havia mais pessoas caminhando, mas só estavam os dois réus na esquina. A ocorrência veio via Copom e não há identificação da pessoa por medo desta sofrer represália. Estavam em operação e havia mais viaturas pelo bairro. É policial em Limeira há oito anos. Já abordou integrantes do Comando Vermelho em Limeira. Não encontrou dinheiro em poder de Brendow e não disse que viu ele consumando o ato de traficância (mídia).

O policial militar Orlando Vieira de Sousa contou que veio ligação de pessoas indicando o local dos fatos e o envolvimento de pessoas com ataques à bases policiais. A ocorrência veio via Copom e foi denúncia anônima. Viram no local o acusado Brendow entregando algo a um motociclista. Os réus foram abordados. O acusado Brendow tinha em seu poder um revólver e bucha de maconha. Indagado, ele disse estar em guerra com quadrilha rival e negou qualquer ataque à forças de segurança. Ele confirmou que estava armado para se proteger de quadrilha adversa. Foi indicado o local e numa árvore encontram mais drogas perto de um playground de crianças. A droga encontrada no relógio do muro era idêntica a encontrada em poder de Brendow. Seu parceiro revistou o acusado Bruno e encontrou mais drogas com ele. Ambos foram algemados e conduzidos ao distrito policial. Ambos estavam juntos quando da abordagem. Não se recorda se Brendow tinha dinheiro. No relógio do comércio e na árvore tinham drogas. Foi apenas Brendow que indicou os entorpecentes. Bruno não apontou os locais porque ele trazia numa pochete os entorpecentes. Informalmente ambos confirmaram a traficância ilícita e que não haveria qualquer ataque aos policiais. Havia mais pessoas transitando no local. Geralmente costuma ter incidentes no bairro, mas como estavam em três viaturas a ocorrência foi tranquila. Quando chegou só estavam os dois acusados no local da abordagem. O que chamou a atenção foi um dos réus entregando algo a um motociclista. A denúncia chega de pessoas apavoradas, de reunião, mas no local só estavam os dois denunciados. Brendow ficou nervoso ao ver a viatura. Eles se

apresentaram como membros do PCC. Por trabalhar na área, ambos já foram abordados e eles sempre dizem que são PCC. Abordou o acusado Brendow que tinha arma em seu poder. Nas outras abordagens nunca encontraram nada em poder deles (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente os réus.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Foram ouvidas testemunhas de defesa.

A testemunha Marcos Antônio dos Santos Junior é amigo do acusado Brendow. Foi ouvida como informante. Ficou sabendo que Brendow tomou um tiro em 2016 da Guarda Civil Municipal. Depois disso o acusado foi preso. O réu Brendow não é traficante e nem integra facção criminosa (mídia).

A testemunha Gilson Ernani Marcelino é amigo do acusado Brendow. Foi ouvida como informante. Não presenciou a prisão. Ficou sabendo por terceiros. Conhece o acusado Brendow há muito tempo. Em 2016 ele tomou um tiro da polícia e ficou internado. Tomou conhecimento dos fatos por amigos. Nunca ouviu falar do envolvimento dele com o tráfico. Sabe que ele tem uma barbearia, é casado e tem filhos. Mora no bairro Recanto Verde (mídia).

A testemunha Brenda Luiza Ferreira é amiga do acusado Bruno. Foi ouvida como informante. Mora perto da casa dele. Nunca viu atividade ilícita de tráfico envolvendo o acusado. Como pessoa sabe que ele é barbeiro, é casado e tem filhos. Tem amizade com a esposa dele chamada Amanda. Nunca ouviu falar dele ser membro de facção criminosa (mídia).

A testemunha Amanda Elizete dos Santos é esposa do acusado Bruno. Foi ouvida como informante. Seu marido foi preso no domingo. Ele foi tomar café na padaria com Brendow. Depois eles iriam jogar bola. Só após ficou sabendo da prisão. Não demorou muito para tomar conhecimento da custódia. Eles não integram facção criminosa. Tem

três filhos com Bruno (mídia).

A testemunha Kawane da Silva é esposa do acusado Brendow. Foi ouvida como informante. Estão juntos há quatro anos. Tem filhos. Seu marido saiu de casa por volta das dez horas da manhã. Depois de quarenta minutos ficou sabendo da prisão dele (mídia).

A testemunha Rafael Henrique Souza é amigo do acusado Brendow. Foi ouvido como informante. Trabalhava no comércio defronte ao local da prisão. Viu os dois parados conversando. Alguém os chamou. Depois ouviu o barulho da polícia. Os dois foram detidos. Os policiais saíram procurando e mexendo pela região. Dois moleques correram, um deixou algo para trás. Sabe que Brendow trabalha. Já são amigos há mais de dez anos, estudaram juntos. Em 2016 ficou sabendo do tiro que ele levou. Ouviu falar por terceiros (mídia).

Passo a analisar os delitos separadamente.

Crime de tráfico de drogas.

Pelo que se verifica da prova oral colhida, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando receberam informações de que os acusados comercializavam drogas em ponto de tráfico e planejavam ataques às bases da polícia local.

No local indicado, os agentes públicos viram o acusado Brendow entregando algo a um motociclista, em atividade típica de tráfico, tendo ao seu lado o corréu Bruno. Em abordagem e submetido à revista pessoal, os policiais encontraram com Brendow uma porção de maconha e um revólver municiado. Indagado, ele confirmou aos guardas a realização do tráfico e a utilização da arma para se proteger de concorrentes, indicando onde guardava a droga.

No local apontado, junto a uma árvore, os policiais encontraram 80 porções de maconha e num relógio de energia 15 pedras de crack.

Por sua vez, o acusado Bruno também foi abordado e numa bolsa que tinha em seu poder foram localizados 23 porções de cocaína, 14 pedras de crack e quantia em dinheiro. Indagado, ele também confirmou a traficância ilícita.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade, a natureza, diversidade e a forma como estavam embaladas as drogas (maconha e cocaína), a delação anônima, as circunstâncias da prisão em flagrante, o encontro de quantia em dinheiro sem justificativa, o local da prisão e o depoimento incriminador dos policiais militares, tudo a apontar os réus como pessoas envolvidas no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 – Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas – Descabimento – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais militares – Credibilidade – Precedentes – Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Ausência de visualização de atos de mercancia – Irrelevância – Tipo misto ou de conteúdo variado – Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosas, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA, Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

A combativa Defesa aponta pequenas divergências e supostas contradições no relato dos agentes públicos para pretender a absolvição, mas sem sucesso, já que pequenos desencontros são comuns e revelam a espontaneidade dos seus relatos.

Observo que não foram arroladas testemunhas de defesa que pudessem corroborar a versão dos acusados de não envolvimento com o delito de tráfico de drogas descrito na denúncia, eis que os testemunhos defensivos se limitaram a mencionar a conduta social e personalidade dos imputados, não tendo presenciado os fatos criminosos, devendo prevalecer o relato dos policiais militares que faziam o patrulhamento preventivo e os prenderam em flagrante delito.

É inquestionável que a ação da Polícia Militar se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal.

Durante o patrulhamento ostensivo e preventivo, os acusados foram abordados em local conhecido pela traficância ilícita, em atitude típica de comércio de drogas em relação ao condutor de uma motocicleta, que resultou no encontro de 9,1g (nove gramas e um decígrama) de cocaína, na forma de vinte e nove pedras de crack, cerca de 9,91g (nove gramas e noventa e um centígramas) de cocaína, na forma de pó, acondicionada em vinte e três porções, e aproximadamente 407,1g (quatrocentos e sete gramas e um decígrama) de maconha, divididas em oitenta porções, quantia em dinheiro e uma arma de fogo municiada, circunstâncias estas que somadas geraram a fundada suspeita da posse de objetos ou substâncias ilícitas, que, por sua vez, autorizaram a busca em conformidade com os artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal.

Nessa direção, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. (...)
1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (...)" 6. Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 685.437/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Hipótese em que o Tribunal de origem, diante das circunstâncias peculiares do caso - veículo parado em atitude suspeita, durante a madrugada, com quatro indivíduos em seu interior - entendeu haver fundada suspeita para a realização da abordagem pessoal, que resultou na apreensão de arma de fogo. A decisão vergastada está em consonância com o art. 244 do CPP e os elementos fáticos consignados no acórdão recorrido são legítimos para fins de busca pessoal. Rever a conclusão do aresto necessitaria do reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1403409/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019).

E não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, das circunstâncias da prisão em flagrante, existindo depoimento incriminador dos policiais militares.

Na esteira dos ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Não é diferente o posicionamento jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecentes - Dolo de traficar - Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) - Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a

substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância.(...)"(TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Note-se que os acusados não tinham trabalho lícito e formal ao tempo dos fatos que lhe propiciasse a aquisição de toda aquela quantidade de entorpecente.

Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - artigo 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/06.

Em conformidade com os relatos dos policiais militares acima mencionados, não pairam dúvidas de que, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, o réu Brendow portava um revólver calibre.38, da marca Rossi, municiado com cinco cartuchos intactos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O laudo pericial de fls. 292/294, por outro lado, não atestou a numeração suprimida da arma de fogo, o que leva a desclassificação para a figura típica prevista no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.

O crime em questão é de mera conduta e de perigo abstrato, não dependendo da ocorrência de efetivo prejuízo a quem quer que seja, tampouco do mau uso da arma, que são presumidos.

Não é caso de reconhecimento de excludentes de ilicitude, pois a situação apurada nos autos não revelou, em qualquer momento, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, modalidades

previstas no art. 23 do Código Penal.

O perigo de agressão futura, por mais verossímil que seja, não passa de hipótese, com a qual não pode cooperar o instituto da legítima defesa, que se constitui numa reação à agressão séria, atual ou iminente.

Desse modo, demonstrada a parcial procedência da imputação contra os réus, não existindo justificativas para seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

BRENDOW WASHINGTON SOUZA TOMAZ.

Artigo 33 da Lei de Drogas.

Na primeira fase, concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são inteiramente favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A natureza e quantidade de drogas apreendidas no caso em tela não justificam a exasperação da pena-base pois não se trata de quantidade elevada.

Na segunda fase, não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes quaisquer causas de aumento. Sendo o réu primário, de bons antecedentes, não havendo prova de que integra organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-se definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Para que fique bem claro, na derradeira etapa do sistema trifásico, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada.

A esse respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário:

“Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda” (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2008).

O valor do dia multa será no mínimo legal.

Considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no acórdão proferido no HC 118.553/MS, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para admitir à fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal.

De fato, o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidendo tantum, do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES.

Dessa forma, fixo o regime inicial aberto para o caso em questão.

Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do Colendo STF, que assim dispõem:

Súmula 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

No mais, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, aplica-se a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na fixação do regime prisional, assim como as decisões dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

Artigo 14 do Estatuto do Desarmamento.

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, com pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda e terceira fase, não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, de modo que torno a pena-base definitiva.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, diante da condição financeira do réu.

Fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena.

Presente o concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, somo as penas para totalizar 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa.

Ante a quantidade da pena imposta, primariedade e tendo em vista a decisão do STF no sentido de que o tráfico privilegiado não pode ser considerado como crime hediondo, além da natureza e quantidade de entorpecente localizada, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, substituto a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser definida em sede de execução criminal.

BRUNO RODRIGO DA SILVA.

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são inteiramente favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula 231 do STJ.

Ausentes quaisquer causas de aumento. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova de que integra organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4ª, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-se definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor do dia multa será no mínimo legal.

Fixo o regime inicial aberto para o caso em questão.

Ante a quantidade da pena imposta, primariedade e tendo em vista a decisão do STF no sentido de que o tráfico privilegiado não pode ser considerado como crime hediondo, além da natureza e quantidade de entorpecente localizada, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser definida em sede de execução criminal.

Com relação ao texto da Lei nº 12.736/2012, pondero óbice no texto completo do art.112 da LEP, que prevê, para a concessão de trânsito de um para outro regime, de vários outros aspectos, não somente o lapso temporal, como bom comportamento carcerário, por exemplo, situação que até agora não foi objeto de apuração.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar BRENDOW WASHINGTON SOUZA TOMAZ, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c a redução prevista no §4º do art. 33, ambos da mesma lei, bem como no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, em concurso material de crimes (artigo 69 do CP).

Também condeno BRUNO RODRIGO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c a redução prevista no §4º do art. 33, ambos da mesma lei.

Substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos nos termos acima fundamentados.

Em razão do regime ora fixado e como responderam soltos ao processo, poderão recorrer em liberdade.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida, com as cautelas de praxe, pela qual representou a autoridade policial.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, assim como da arma.

Após o trânsito em julgado, o nome dos réus deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.

Limeira, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA